

1500189-60.2021.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

...

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

2ª Vara

Av. Presidente Vargas, 131, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500189-60.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-60.2021.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO FAVARETTO e outro

Vistos etc.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de Matheus Aparecido Ribeiro e Eduardo Favaretto, devidamente qualificados às fls. 07/08, dos autos deste processo crime, dando-os como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 25 de setembro de 2021, no posto Rio Paraná, situado na Rodovia SP 270, km 654, nessa cidade e Comarca de Presidente Epitácio, Matheus Aparecido Ribeiro e Eduardo Favaretto, em concurso, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, estariam transportando, para entrega onerosa ao consumo de terceiros, uma porção de Cannabis Sativa L, pesando aproximadamente 4,4 gramas, 21 porções de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 3,0 gramas, bem como 06 porções de cocaína em pó, com peso aproximado de 4,90 grama, drogas essas capazes de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 30/09/2021 (fls. 181/183), os réus foram regularmente citados (fls. 201 e 203) e ofereceram defesas prévias (fls. 208, 299/310).

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 280/291).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 319/321), prosseguiu-se à fase

instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou pela condenação do réu Matheus pelo delito descrito na denúncia, bem como do réu Eduardo pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva. As Defesas pugnaram pela absolvição dos acusados e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO .

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de Matheus Aparecido Ribeiro e Eduardo Favaretto pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante dos réus (fls. 05/07), do boletim de ocorrência (fls. 15/19), do auto de exibição e apreensão (fls. 20/23), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 24/25) e dos laudos periciais químico de entorpecente (fls. 280/291).

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída aos acusados Matheus Aparecido Ribeiro e Eduardo Favaretto. Contudo, em relação a este, como se verá, a conduta não se subsume ao artigo 33 da Lei 11.343/06, mas sim ao artigo 28 desta lei.

Inquirida, a testemunha Neumir César da Cunha Carminatti, policial militar, relatou que na data dos fatos em patrulhamento avistaram um veículo estacionado próximo a saída do posto Paraná, e ao aproximarem visualizaram Matheus já conhecido pela prática do tráfico na cidade. Disse que abordou o acusado Matheus, enquanto seu colega abordou Eduardo. Mencionou que ao pedir para descer, viu que Matheus escondeu algo embaixo do tapete. Asseverou que em revista localizou com Matheus R\$ 80,00 e um celular. Narrou que em revista no veículo localizaram os entorpecentes. Declarou que seu colega localizou com Eduardo um celular e uma porção de cocaína semelhantes as de Matheus. Afirmou que indagado, Matheus disse que as drogas eram de sua propriedade e seriam para o seu consumo próprio, enquanto que Eduardo disse que era usuário de cocaína e estaria indo para a orla. Acrescentou que todas as porções de entorpecentes localizadas estavam embaladas prontas para a venda. Esclareceu que Eduardo, indagado, dizia frases desconexas.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Gustavo César Leite. Complementou dizendo que Matheus faz parte de uma associação criminosa, como disciplina, na cidade. Narrou que abordou Eduardo e localizou com ele um celular e uma porção de cocaína. Disse que em revista no automóvel localizaram 21 porções de crack, 5 porções de maconha e 06 de cocaína, todas prontas e embaladas para a venda. Acrescentou que Eduardo dizia frases desconexas, não sabendo informar se estava sob efeito de álcool ou droga.

A testemunha de defesa Maurício Hay Mussi Cavalcante, afirmou que conhece Eduardo e sabe dizer que ele trabalha como pintor. Disse que nunca viu Eduardo traficando. Mencionou que conheceu Eduardo na época da escola. Declarou que Eduardo é usuário de drogas. Acrescentou que nos finais de semana Eduardo realizava serviços como motorista com o seu carro.

A testemunha Maicoo dos Santos Costa, afirmou que trabalha como funcionário público e conhece o acusado Eduardo pois também trabalha como pintor nas horas vagas e já trabalharam juntos em três ou quatro serviços. Asseverou que nunca viu Eduardo traficando, bem como nunca soube de nada que o desabonasse. Mencionou que o último trabalho que fizeram juntos foi próximo ao Banco do Banespa num escritório de advocacia.

A testemunha Robison Frank Assis Silva, afirmou que conhece o acusado Eduardo pois havia contratado ele para trabalhar na fazenda dois dias antes dos fatos. Narrou que por conta dos fatos acabou contratando outra pessoa para trabalhar, inclusive, um rapaz que trabalhava para Eduardo. Disse que nunca soube nada que desabonasse a conduta de Eduardo.

Em juízo, o acusado MATHEUS APARECIDO RIBEIRO, negou os fatos narrados na denúncia.

Afirmou que as únicas drogas que tinha eram três porções de cocaína e uma porção de maconha que estava levando para a festa. Negou que estivesse com pedras de crack. Alegou que as drogas eram para o seu consumo próprio. Disse que pagou R\$ 130,00 pela droga, na Vila Esperança. Mencionou que comprou a droga no dia 24, um dia antes, com o dinheiro proveniente do seu serviço. Esclareceu que não conhecia Eduardo, apenas contratou ele como uber. Acrescentou que possuía várias porções porque foi assim que comprou, sendo que não tem como comprar uma porção só. Por sua vez, interrogado em juízo, EDUARDO FAVARETTO, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que no dia dos fatos estava altamente embriagado, e por conta da depressão e síndrome do pânico, tinha se medicado em data anterior. Declarou que não se recordava que tinha porção de droga no seu bolso. Mencionou que usava droga uma vez ou outra. Disse que não conhecia e nunca tinha visto Matheus. Negou que tivesse comprado drogas de Matheus. Aduziu que no dia dos fatos estava trabalhando como motorista.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que as palavras do acusado Matheus encontra-se em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pelas louváveis defesas.

Dar-se crédito àqueles que são detidos em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No caso concreto, o acusado Matheus, diferente do que alega, foi surpreendido com 21 invólucros de cocaína em forma de crack, bem como 6 porções de cocaína em pó e uma porção de maconha.

A sua alegação de que tinha apenas a cocaína em pó e a maconha não prospera, vez que desprovida de qualquer elemento probatório nesse sentido. Em contraponto, as 21 porções de droga foram encontradas no carro onde estava Matheus, sendo que os policiais afirmaram que o viram esconder algo no tapete do veículo.

Veja-se que não há qualquer indicação de que os policiais militares tenham forjado ou plantado a droga com a intenção de incriminar Matheus. Desta forma, imperioso reconhecer que a versão deste acusado não prospera, sendo forçoso concluir que toda a droga encontrada nos autos lhe pertencia, à exceção da pequena porção encontrada com Eduardo.

É imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

E, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

Existe um nex o íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Outrossim, o fato de o acusado ser usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do delito de traficância.

Pelo contrário, não é raro que usuários passem também a comercializar entorpecentes justamente para garantir o próprio vício, acrescentando-se, por oportuno, que uma

conduta não exclui a outra: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJSP 101/498). Ademais, como também reconhecem os tribunais: "Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325).

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a variedade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado Matheus (cocaína, crack e maconha); a relevante quantidade de entorpecente (4,4 gramas de maconha, 3 gramas de crack, e 4,90 gramas de cocaína em pó); o modo de acondicionamento (uma porção de maconha, 21 porções de crack e 06 porções de cocaína, embaladas individualmente); o depoimento dos policiais, revelam que se tratava mesmo das práticas do tráfico e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, em relação ao acusado Matheus, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contraponto, com o acusado Eduardo somente foi encontrada 1 porção de cocaína, sendo que este afirma que não se lembra de ter utilizado drogas naquele dia, mas que, no período em que ocorreram os fatos, costumava utilizar drogas.

A pequena quantidade de drogas encontrada com este réu, diferentemente do que encontrado com o réu Matheus, indica que Eduardo não realizava a traficância, mas apenas o uso de entorpecentes. Ademais, não restou evidenciada qualquer ligação entre Eduardo e Matheus, sendo impossível atribuir-se àquele a copropriedade das drogas que Matheus possuía.

Assim, em relação à Eduardo, é caso de desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

I - MATHEUS APARECIDO RIBEIRO

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são desfavoráveis. Isso porque a par da reincidência do acusado, que será valorada em momento oportuno, a natureza e diversidade das drogas (cocaína em pó e em forme de crack e maconha) implicam em gravidade exacerbada do delito, o que justifica a exasperação da pena-base.

Na segunda fase de dosimetria, encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 504/507), de modo que elevo a pena intermediária em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase de cálculo penal, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente. Desta feita, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, à míngua de outros elementos modificativos.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas, uma vez que o réu demonstrou ter condições econômicas para arcar com tal valor.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu e da reincidência.

E, pelos mesmos motivos já explanados, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

II - EDUARDO FAVARETTO

Considerada a primariedade do réu, o condeno à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06.

DECIDO.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:

1) CONDENAR MATHEUS APARECIDO RIBEIRO, já qualificada nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não há como se estender ao acusado o entendimento exarado no Habeas Corpus que concedeu a liberdade provisória ao acusado Eduardo. Isto porque Eduardo é primário, enquanto que Matheus é reincidente, o que denota sua periculosidade e habitualidade delitiva. Ademais, as circunstâncias do delito são diferentes para os acusados, sendo que Matheus aqui está sendo condenado pelo delito de tráfico de drogas, enquanto que Eduardo será condenado apenas pelo delito de uso de entorpecentes.

No mais, os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva continuam presentes, sendo que o fato do acusado ter trabalho lícito não basta para a concessão da liberdade provisória. Ainda, não faz sentido que o acusado tenha aguardado julgamento preso e agora, condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, seja colocado em liberdade.

2) CONDENAR EDUARDO FAVARETTO, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso na pena do artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em relação a este acusado, na esteira do que pugnou o Ministério Público, tendo em vista que já permaneceu preso preventivamente por diversos meses, reconheço EXTINTA SUA PUNIBILIDADE pelo cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração.

Condeno os réus nas custas processuais, ressalvada a hipótese de serem beneficiários de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre as condenações dos réus.

Arbitro os honorários dos defensores dos acusados no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Presidente Epitácio, 02 de junho de 2022.

Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Juiz(a) Substituto(a)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA